

1501116-18.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Imbrunito Flores

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... de drogas. Nesse sentido: 'Tráfico de entorpecente. Réu flagrado por trazer consigo 39 gramas de cocaína (19 porções). Notícia anônima detalhada. Depoimentos dos policiais militares. Condenação pelo delito de tráfico que deve ser mantida. A configuração do crime de tráfico ou de posse para consumo próprio não se submete apenas à análise da quantidade de droga ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

2ª Vara

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, ., Jardim Guanabara - CEP 13190-000, Fone: (19)

2141-2606, Monte Mor-SP - E-mail: montemor@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501116-18.2020.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2213751/2020 - DEL.POL.MONTE MOR, 13277330 - DEL.POL.MONTE MOR, 1699/20/330 - DEL.POL.MONTE MOR, 2213751 - DEL.POL.MONTE MOR, 1699/20/330 - DEL.POL.MONTE MOR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bismarck Rodrigues dos Santos

Vítima:

Saude Publica

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

22/02/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Iniciados os trabalhos às 16h30, verificou-se a presença do MM. Juiz RAFAEL IMBRUNITO FLORES; do(a) Dr(a). Cristiane de Moraes Ribeiro Sampaio Carvalhaes de Camargo, DD. 1ª Promotora de Justiça; presente a(o) ré(u) BISMARCK RODRIGUES DOS SANTOS, acompanhado(a) de seu/sua defensor(a), o(a) Dr(a). Roberta Aparecida Annichino Batagin. De início, pelo MM. Juiz restou consignado que a presente

audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade/restrição de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns. A seguir, foi ouvida a testemunha José Prado Moitinho, arrolada em comum, após o que foi o réu interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito ainda: “Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual. Passe-se aos debates”. Com a palavra o(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, após o que se manifestou a defesa, também oralmente, captada por sistema audiovisual. Os depoimentos e manifestações colhidos nesta data foram captados por sistema audiovisual (Microsoft Teams) e o arquivo de gravação foi importado no sistema SAJ, estando disponível no próprio processo, atrelado a este termo de audiência, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte SENTENÇA: “VISTOS. BISMARCK RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 35, caput, e no artigo 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, ambos c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, e na forma do concurso material, previsto no artigo 69, caput, também do Código Penal, porque, como narra a denúncia, em local e dia incerto, mas anterior ao dia 29 de agosto de 2020, em época de reconhecida calamidade pública, associou-se à pessoa precariamente identificada como 'Geovana' e a outros indivíduos não identificados, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas; e também porque, no dia 29 de agosto de 2020, por volta das 21h30min, em época de reconhecida calamidade pública, na Rua Vinte e Três, nº 315, Jardim Nova Alvorada, nesta cidade e comarca de Monte Mor, agindo em concurso e com unidade de desígnios com pessoa precariamente identificada como 'Geovana' e com outros indivíduos não identificados, tinha em depósito, para consumo de terceiros, 20 (vinte) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi preso em flagrante, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante pagamento de fiança em decisão de págs. 54/55. Denúncia ofertada às págs. 74/81 e, devidamente recolhida a fiança, foi expedido alvará de soltura (págs. 105/107). Notificação do réu às págs. 143, sendo-lhe nomeada defensora dativa, a qual apresentou defesa prévia às págs. 152, sem arguição de preliminares. Denúncia recebia em decisão de págs. 154/155, oportunidade em que também foi designada audiência virtual de instrução, debates e julgamento virtual para 07/10/2021. Citação do réu às págs. 173. Em audiência foi ouvida uma testemunha comum e designada audiência em continuação para hoje, ouvindo-se a testemunha restante e interrogando-se o réu. Houve debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Anoto de proêmio que não se vislumbra qualquer nulidade nos autos. A questão atinente à impossibilidade de a guarda municipal efetuar prisão já se encontra superada na jurisprudência, eis que qualquer do povo, incluindo-se aí os guardas municipais, pode efetuar prisão de quem se esteja em flagrante. No mais, percebe-se que a investigação ficou a cargo da polícia civil, que detém competência para tanto. O pedido penal condenatório deve ser julgado parcialmente procedente, com a condenação do réu apenas pelo crime de tráfico de entorpecentes. A materialidade ficou delimitada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 01/04), boletim de ocorrência de págs. 05/07, auto de exibição e apreensão de págs. 08 e laudo de exame químico-toxicológico (págs. 116/117). A autoria é inconteste. O réu, em sede inquisitiva, nada disse. Em Juízo, negou a prática do tráfico, alegando que conheceu Geovana naquela mesma data, não sabendo dizer porque os guardas disseram tê-lo visto realizando vendas. Os guardas municipais narraram que receberam denúncia no sentido de que duas pessoas, um homem e uma mulher, realizavam o narcotráfico na praça do bairro Jardim Nova Alvorada e, então, dirigiram-se ao local, posicionaram-se em lugar estratégico e puderam observar que um homem de deslocava para o interior da praça, pegava algo no meio de entulhos e entregava a terceiros, que lhe entregavam dinheiro, que era repassado para uma mulher que ficava junto dele na praça. A mulher, então, entrou num veículo e saiu do local. A movimentação do homem suspeito foi visualizada mais uma vez e então procederam à abordagem, identificando o indivíduo como o ora réu. Em revista pessoal, localizaram uma nota de R\$ 10,00 e um aparelho celular, e, indagado,

inicialmente negou a prática do tráfico, porém, quando informado de que estava sendo observado, admitiu a prática do tráfico de drogas, indicando aos agentes públicos onde estavam as drogas (vinte porções de cocaína), além de dizer que o dinheiro das vendas havia sido entregue para mulher de nome Geovana, que seguiu com outro indivíduo até a cidade de Hortolândia. Em Juízo, confirmaram a versão, acrescentando que o dinheiro das vendas eram entregues tanto para Geovana quanto para o réu nas duas oportunidades que flagraram quando da campana. Informaram que a denúncia anônima dava conta de que os traficantes eram um casal, bem como que o réu confirmou que a Geovana se encarregava do dinheiro. Este foi o relatado. Pelo que se vê, de rigor a condenação do réu pelo cometimento de tráfico de drogas. Os guardas prestaram versões uníssonas e seguras no sentido de que, depois de receberem denúncia anônima, presenciaram o réu realizando duas entregas de entorpecentes a compradores, recebendo dinheiro. Depois de abordado, o réu acabou confessando informalmente que realizava o narcotráfico naquele ponto, pese embora tenha negado nesta data, apresentando versão pouco crível. Evidente, pois, que o réu guardava entorpecentes destinados à venda, incorrendo nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, quer seja pela conduta do agente quer pela denúncia anônima, a despeito da pouca quantidade de drogas. Nesse sentido: 'Tráfico de entorpecente. Réu flagrado por trazer consigo 39 gramas de cocaína (19 porções). Notícia anônima detalhada. Depoimentos dos policiais militares. Condenação pelo delito de tráfico que deve ser mantida. A configuração do crime de tráfico ou de posse para consumo próprio não se submete apenas à análise da quantidade de droga apreendida, devendo outras circunstâncias ser consideradas, tais como o local do flagrante, a conduta e os antecedentes do agente, a existência de notícia anônima. Mormente por considerar a prática comum entre os traficantes de portar poucas porções visando a evitar eventual condenação pelo narcotráfico. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor não aplicado em razão de processos em andamento. Impossibilidade. Ofensa ao princípio da presunção de inocência. Reconhecimento do redutor em grau totalmente favorável. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento' (TJSP, Ap. 0000053-31.2014.8.26.0150, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 02.06.15). Não há nos autos qualquer notícia de animosidade prévia entres os agentes que realizaram a prisão e o réu, razão pela qual suas versões devem ser acolhidas, já que prestadas sob juramento. Nesse sentido: 'Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contrassenso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígios do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plusvalia, mas também sem preconceito (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).' Não vinga, todavia, a pretensão penal referente ao delito de associação, uma vez que as provas colacionadas não demonstraram, de forma inequívoca, o liame associativo entre o acusado e outras pessoas, de caráter duradouro e estável. Para a configuração deste delito 'exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. (...) é fundamental que os ajustes se reúnam com o propósito de manter uma meta comum' (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 334). Esse é o posicionamento do STJ: 'O tipo previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo' (REsp 1113728-SC, 5ª T., rel. FELIX FISCHER, j. 29.09.2009, v.u.). Outro não é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: 'Apelação Criminal. (...) Associação Criminosa. Melhor a absolvição. Nada de concreto a indicar estabilidade e permanência do ajuste entre os acusados. Demonstração de mera comparsaria episódica, apta a configurar apenas o concurso eventual, mas não o crime em apreço. (...)'. (Apelação 0000127-59.2010.8.26.0495 -

Rel.

Des. PÉRICLES PIZA, 1ª Câmara de Direito Criminal, 06/06/2011). Este juízo tem adotado o entendimento no sentido de que se exige mais que o mero concurso para que o crime se configure. Tal se dá já que eventual concurso eventual não há de ser tido como crime autônomo. E, em que pese a insurgência ministerial, os recursos tirados contra tais decisões não têm sido acolhidos, o que somente reforça o acerto da decisão. Nestes termos: "APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Pleito ministerial para condenação, também, pela associação para o tráfico e afastamento do privilégio – Ausência de prova suficiente da associação entre os réus para a prática delitiva ou de dedicação a atividades criminosas outras – Dosimetria adequada - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, Ap. 1500585-65.2019.8.26.0372, Rel. Des. Edison Brandão, j. 26.01.21). Por fim, em que pese esforço ministerial, fato é que não vinga o pedido de reconhecimento da agravante a que se refere o artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. Com efeito, não há prova de que o agente se valeu da situação de calamidade pública para cometer o crime. Anoto, inclusive, que o E. TJSP já assim decidiu, inclusive em recurso de apelação tirado contra sentença deste Magistrado, que igualmente não reconheceu a incidência da agravante. Confira-se: 'APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso ministerial. Pleito de reconhecimento da agravante previsto no artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP. Impossibilidade. Inexistência de indícios de que o delito foi cometido em razão da pandemia ou de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública. Pena mantida. Exasperação do regime prisional fixado para cumprimento da reprimenda. Inadmissibilidade. Primariedade do acusado e quantum da pena aplicada que autorizam a fixação do regime inicial aberto. Negado provimento ao recurso ministerial (TJSP, Ap. 1501706- 94.2020.8.26.0372, Rel. Des. Leme Garcia, j. 23.02.21). E não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 'Com relação a agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em tese seria cabível em desfavor do paciente, em face da crise causada pela pandemia, de ordem, econômica, social e sanitária, já que o crime foi cometido na vigência do Decreto Legislativo 6/2020, de 20/03/2020. Todavia, a despeito da prática do crime em ocasião de calamidade pública e do desvalor, sem dúvida, da conduta do paciente, não é suficiente, a meu sentir, a existência do Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública para incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância, e isso não foi devidamente demonstrado na hipótese em análise.' (STJ Decisão Monocrática Min. Rel. Felix Fischer HC n. 620.363/SP publicado em 18.11.2020). O que se tem, pois, é a parcial procedência da pretensão inicial, condenando-se o réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, absolvendo-o, contudo, do crime de associação para o tráfico, afastando-se a agravante descrita na denúncia para os dois crimes. Comprovada a autoria e a materialidade dos crimes, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, observo que o réu é primário. Assim, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, cada um no mínimo legal, para o crime de tráfico. Na segunda fase, mantenho a pena-base, ainda que reconhecida eventualidade relativa. Na terceira fase, de acordo com a Lei 11.343/06, são necessários quatro requisitos para que o benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 seja aplicado, a saber: primariedade; bons antecedentes; não se dedicar a atividades criminosas; e, nem integrar a organização criminosa. Tais requisitos, cumulativos, se entremostam presentes no presente caso. Com efeito, o réu é primário, não ostenta outros antecedentes ou passagens criminais, pese embora esteja respondendo por crime de roubo nos autos de nº 1501304-47.2019.8.26.0372, o que, por si só, não é suficiente para impossibilitar a incidência. A diminuição pode se dar em 2/3, atingindo o montante de 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, no piso. À mingua de outros elementos de prova, estas penas se tornam definitivas. Com relação ao regime inicial de cumprimento, é certo que até dezembro de 2021 pendia a existência de decisão oriunda do E. Superior Tribunal de Justiça, que concedia o direito de regime inicial de cumprimento como aberto, permitida a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Este Magistrado possui o entendimento de que o regime de cumprimento, ainda que incidente a causa de diminuição, deveria ser o fechado, em

razão da gravidade do crime e o mandamento constitucional de que tal modalidade criminosa há de ser tratada com maior rigor. Mas, em razão da decisão, havia a obrigação de a ela me curvar. Agora, como dito, o Supremo Tribunal Federal cassou tal decisão, por meio do RE 1344374, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ao entender que não se mostra cabível a concessão de habeas corpus genéricos, sem a individualização das pessoas beneficiadas. Destarte, feitas tais ponderações, o regime inicial de cumprimento deve ser o fechado. Além disso, as consequências do crime de tráfico são extremamente maléficas e, é cediço, trata-se de crime que fomenta inúmeros outros: lavagem de dinheiro, homicídio em disputas por pontos de tráfico e porte de armas de fogo. Exige-se, pois, a fixação de regime inicial de cumprimento mais severo, com o fito de impedir o cometimento de crimes como este. Pelos mesmos motivos, nego ao réu o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, podendo, contudo, recorrer em liberdade. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido penal condenatório para o fim de CONDENAR o réu BISMARCK RODRIGUES DOS SANTOS como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa, no piso, em regime fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade; bem como para ABSOLVÊ-LO do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Isento o réu do pagamento das custas, uma vez que acompanhado de advogado dativo. Arbitro os honorários do patrono nomeado no patamar máximo. Expeça-se certidão. Determino o perdimento dos valores apreendidos, e também dos pagos a título de fiança, bem como do celular apreendidos, todos em favor da União. Publicada nesta audiência. Saem os presentes intimados. Registre-se". Por fim, dada a excepcionalidade da audiência virtual, consigno em termo que o Ministério Público não irá recorrer desta sentença e que o réu, por meio de seu/sua advogado(a), decidiu recorrer desta sentença. NADA MAIS. Eu, Adriano Esmael Gazzola, Escrevente Técnico Judiciário, matr. 364.087-A, digitei. CERTIFICO e dou fé que as partes presentes nesta audiência tiveram ciência do inteiro teor da r. decisão/sentença.

RAFAEL IMBRUNITO FLORES
Juiz de Direito